



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000769290

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004339-51.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante JOSÉ DOS SANTOS ZUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.

São Paulo, 4 de outubro de 2017.

FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação nº 0004339-51.2015.8.26.0624

Apelante: José dos Santos Zuza

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Tatuí

Voto nº 17.642

Lesão corporal – Violência doméstica - Recurso defensivo alegando, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa. No mérito, pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a dispensa das custas processuais – Preliminar afastada – Inocorrência de violação das regras da *Emendatio Libelli* – Devido processo legal respeitado – Princípio da correlação respeitado – Réu que se defendeu dos fatos durante toda a instrução – Mérito – Provas francamente incriminadoras – Declarações seguras prestadas pela vítima Luana e pela ex-companheira do réu – Laudo pericial comprovando a lesão corporal experimentada pelas vítimas – Pena e regime fixados critério – Impossibilidade de dispensa do pagamento das custas – Apenas o Juízo da Execução poderá dispensá-lo do pagamento, após aferir a real situação financeira do apelante – Negado provimento.

Adotado o relatório da r. sentença de fls. 121/126, acrescenta-se que o réu **JOSÉ DOS SANTOS ZUZA** foi condenado, como incurso no art. 129, § 9º, por três vezes, na forma do art. 70, *caput*, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado, apela o réu (fls. 130), pleiteando a absolvição do, seja porque a r. sentença fere o princípio da correlação,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

seja por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime para a modalidade culposa. Por fim, requer gratuidade de justiça (fls. 131/133).

Regularmente processado o recurso, nesta instância, o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo (fls. 157/163).

É o relatório.

Apesar de ter a combativa defesa tratado da questão da *emendatio libelli* e o princípio da correlação como matérias meritórias, entendo que, pela melhor técnica jurídica, devem ser analisadas em sede de preliminar.

E, neste ponto, a alegação deve ser rechaçada.

Embora a peça incoativa tenha imputado ao réu a prática de lesões corporais culposas, por três vezes, e a r. sentença o condenou pelo crime descrito no § 9º do art. 129 do Código Penal, não há se falar em desrespeito ao Princípio da Correlação.

O magistrado *a quo*, ao proceder dessa maneira, utilizou-se do instituto processual denominado *emendatio libelli*, capitulado no art. 383 do Código de Processo Penal: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”.

Dessa maneira, o juiz não está atrelado à definição jurídica contida na denúncia.

Nesse sentido, doutrinariamente, temos que:

“[...] a denúncia ou queixa são peças eminentemente formais e devem descrever com fidelidade e clareza a conduta efetivamente praticada. Impõem-se tais cautelas, pois ao acusado se defende dos fatos contra ele imputados na inicial e não da simples classificação jurídica formulada pelo Ministério público. Em outras palavras, a sentença a ser proferida deverá cingir-se à apreciação da imputação contida na denúncia, sob pena de tisonar o contraditório e a ampla defesa (TACRIM/SP Apelação nº 478.797/3, Rel. Juiz Luiz Pantaleão, RJDTACRIM 2/159. No mesmo sentido: RDTTACRIM 8/163). [...] O réu, como foi dito, defende-se dos fatos irrogados na denúncia ou na queixa e não da capitulação delitiva dada pelo acusador. Dessa forma, nos termos do art. 383 do CPP, quando o juiz discordar da classificação contida na peça acusatória, poderá dar ao fato (fato contido na denúncia ou queixa, implícita ou explicitamente), definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (STF, 2ª T., HC 73.389-SP, Rel. Min. Maurício Correa, DJ 06.09.1996, p. 31.581; STF, 2ª T., HC 74.553-RS, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 13.12.1996).”

(DEMERCIAN, Pedro Henrique e MALULY, Jorge Assaf, *Curso de Processo Penal*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 6ª edição, p. 556).

Em sendo assim, depreende-se que as lesões corporais dolosas foram narradas na denúncia, pelo que o reconhecimento da modalidade dolosa na r. sentença não fere o Princípio da Correlação.

Com efeito, não há se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de aplicação do art. 383 do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Código de Processo Penal, vez que, repise-se, a defesa deve atacar os fatos narrados e não a capitulação jurídica a eles impressa.

Aliás, a doutrina entende que:

“A defesa – autodefesa e defesa técnica – volta-se aos fatos imputados e não à classificação feita. Não vemos praticidade na conduta do magistrado que, estando com o processo em seu gabinete para sentenciar, após verificar que não é o caso de condenar o réu por estelionato, mas sim por furto com fraude, por exemplo, paralisa seu processo de fundamentação, interrompe a prolação da sentença e determina a conversão do julgamento em diligência para o fim de ouvir as partes sobre a possibilidade – não poderá afirmar que assim fará, pois senão já estará julgando, em decisão nitidamente anômala – de aplicar ao fato definição jurídica diversa da constante nos autos. [...] O réu – autodefesa- apresentará a sua versão dos fatos que o juiz lhe narrar, conforme a denúncia ou queixa. O seu defensor analisará, criteriosamente, os mesmos fatos e promoverá, de acordo com seu entendimento, a classificação cabível no interesse da ampla defesa, desprezando, para esse fim, o que foi capitulado na denúncia ou queixa.” (NUCCI, Guilherme de Souza, *Código de Processo Penal Comentado*, 13ª edição, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014, pp. 787/788).

Desta forma, verifica-se que também não há qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa no caso dos autos, pelo que, afasta-se a preliminar defensiva.

No mérito, verifica-se que a r. sentença monocrática



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

merece ser mantida por seus próprios fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos autos, pelo que a condenação do apelante era mesmo de rigor.

A materialidade e a autoria estão bem comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 36/40, dos laudos de exame de corpo de delito (fls. 59/60, 61/62 e 63/64), do laudo do dano (fls. 65/66) e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, emergindo absoluta certeza de que o réu agiu com dolo eventual, quebrando uma porta de vidro, cujos estilhaços atingiram as vítimas, causando-lhes lesões corporais de natureza leve.

Com efeito, a vítima descreveu detalhadamente como se deram os fatos, confirmando a conduta dolosa do réu.

A vítima Luana, ao ser ouvida em juízo, em relato emotivo, disse que, no dia dos fatos, estava em casa, na sala, com sua filha e sua sobrinha, enquanto que Daniela estava dando banho na filha mais nova do casal. Nesse momento, o réu exigiu falar com Daniela, mas a vítima disse que ela não podia atender porque estava cuidando a filha. Então, o réu disse que não importava o que ela estava fazendo, mas queria falar com ela. Disse que o réu ameaçou, dizendo que se Daniela não saísse para atendê-lo, entraria para buscá-la. Por essa razão, fechou a porta e disse que ele não adentraria na casa. Quando o réu percebeu que a porta estava trancada, passou a esmurrá-la, até quebrar os vidros. Os estilhaços atingiram o rosto de sua filha, ficando



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

ensanguentada, assim como o rosto de seu sobrinho Brian. Disse que também foi atingida e passou semanas com o rosto inchado. Disse que, quando ele viu que as crianças tinham se machucado, fugiu de bicicleta. Esclareceu que o réu já havia passado em frente à casa, procurando por Daniela, o que fazia todos os dias. Explicou que, na separação dos dois, ele reteve os documentos de Daniela, e os utilizava como pretexto para encontrá-la e entregar um por vez. Acerca da personalidade do acusado, esclareceu que ele tinha o costume de beber e dirigir, que ameaçava a ex-esposa, Daniela, sendo que até os filhos tinham medo dele. Disse que a família passou a viver de portas e janelas trancadas com medo do réu, que circundava a casa sempre. Relatou que havia histórico de violência do réu contra Daniela (mídia).

Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral colhida. Sabidamente, nos crimes de violência, a palavra da vítima é de vital importância para provar o delito, até mesmo porque, muitas vezes, inexistentes outros meios de provas. Ademais, não evidenciado nos autos qualquer motivo para considerar falsa a imputação.

Nesse sentido:

"PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DELITO DE AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Nos crimes praticados dentro do ambiente domiciliar tipificados pela Lei Maria da Penha a palavra da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

vítima assume extrema importância, ainda mais quando confirmada por outros indícios veementes, se apresentando suficiente ao decreto condenatório, independente da negativa de autoria do acusado, especialmente porque praticados normalmente na clandestinidade, ausentes quaisquer testemunhas presenciais". (TJMG - Relator: Desembargador Pedro Vergara - Processo nº. 0076670-55.2007.8.13.0177 - Data do Julgamento: 15/12/2009 - Data da Publicação: 03/02/2010).

Com efeito, a testemunha Daniela relatou que, no dia dos fatos o réu havia passado alcoolizado pela sua casa querendo falar com ela. Disse que, no dia dos fatos, o réu queria entrar para falar com ela, mas sua cunhada negou que ele entrasse na casa e fechou a porta. Por essa razão, ele passou a dar murros na porta, cujos vidros quebraram. Disse que os estilhaços atingiram sua sobrinha, seu filho e a cunhada. Esclareceu que a porta permite que seja vista a parte de dentro da casa. Relatou ter sido agredida pelo réu por diversas vezes, tendo registrado diversas ocorrências junto à autoridade policial. Também disse que foi ameaçada de morte por diversas vezes pelo réu, sendo que ele a perseguiu, com uma faca na mão pela rua. Confirmou que havia medida protetiva de afastamento. Disse que ele ainda manda mensagens para saber dela (mídia).

Em complemento, os autos de exame de corpo de delito de fls. 59/60, 61/62 e 65/66, realizados com base nos receituários médicos, descreveram as lesões experimentadas pelas vítimas: ferimento corto contuso em Brian e Nayla, e escoriações na face à direita de Luana, todas compatíveis com a versão narrada pela vítima.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

De outra banda, o réu, em seu interrogatório, disse que, no dia dos fatos, estava com muita saudade de seus filhos e, ao ser negada a visita, foi a um bar e consumiu cervejas. Após, retornou para a casa de sua ex-sogra para tentar ver os filhos, oportunidade em que sua ex-cunhada, Luana, não permitiu sua entrada. Então, admitiu ter dado murros nos vidros da porta, mas negou a intenção de machucar as vítimas. Disse que a casa de sua sogra é pequena e que sabia que as crianças estavam lá dentro (mídia).

Assim, o réu, com sua conduta, assumiu o risco de causar lesões corporais nas vítimas, agindo com dolo eventual, constatando-se que tinha conhecimento de que a porta da casa era de vidro e que as crianças e demais pessoas estavam dentro do local, o qual disse ser pequeno, sendo inviável desclassificar a conduta para a modalidade culposa.

De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.

A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada, considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

condições pessoais do apelante, não comportando reparo.

O réu é detentor de personalidade deturpada, voltada ao cometimento de crimes no seio familiar, conforme certidão de fls. 81, como bem salientado pela d. magistrada sentenciante, o que justifica a majoração da pena base.

Ainda, bem operado o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso formal de crimes, considerando que, mediante uma ação, causou lesões corporais leves em três vítimas.

Diante da personalidade do réu e por ter sido o crime praticado com violência à pessoa, o réu não preenche as condições para a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos ou a concessão do *sursis*.

A conduta ilícita perpetrada pelo réu contra as vítimas se enquadra na forma de violência doméstica, nos termos da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). E, na esteira da Constituição da República e de tratados internacionais, o ordenamento jurídico veio reconhecer a gravidade, a complexidade e a peculiaridade da violência doméstica, restringindo benesses ao agente e demandando maior rigor desta Corte.

O regime prisional (aberto) foi estabelecido com critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

reprovabilidade da conduta criminosa.

Finalmente, descabida a dispensa do pagamento das custas processuais pelo apelante nesta oportunidade.

É firme na jurisprudência que o acusado, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

A almejada isenção somente poderá ser concedida ao recorrente na fase de execução do julgado, porquanto esta é a etapa adequada para se aferir a sua real situação financeira, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, ficando refutada eventual alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Sobre o tema:

“No processo penal, assim como no processo civil, impera o princípio que proclama a obrigação do vencido arcar com as despesas do processo, com destaque para as custas processuais (C.P.P., art. 804). Em se tratando de réu miserável, beneficiário da garantia constitucional da assistência jurídica integral gratuita, não há exoneração do pagamento da obrigação, que, todavia não se exigirá na hipótese de prejuízo do sustento próprio ou da família, ficando a mesma prescrita se no prazo de cinco anos, contados da sentença, não puder satisfazê-la (Lei nº 1.060/50, art. 12)” (STJ – REsp. nº 108.267/DF – Rel. Min. Vicente Leal – j. 12.05.97).

Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

condenatória, dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é da manutenção integral, sob os fundamentos jurídicos constantes a fls. 121/126.

Ante o exposto, por meu voto, **afastada a preliminar, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO** ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

FERNANDO SIMÃO
Relator